

1501244-04.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... consolidado pela Corte Suprema, que o tráfico de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06) não é crime equiparado a hediondo, cancelando a súmula 512, editada em 2014 após o julgamento do REsp 1.329.088 sob o rito dos repetitivos.

Enfim, estando pacificada nas Cortes Superiores a não hediondez do tráfico privilegiado, sendo o réu primário ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501244-04.2021.8.26.0599 - Controle nº 2021/000919

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2217400/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 19558587 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 58/21/594 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 2217400 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS ALBERTO DE SOUSA

Aos 23 de fevereiro de 2022, às 17:00h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 em razão da pandemia do coronavírus, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dr. CLÁUDIO JOSÉ BAPTISTA MORELLI - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: LUCAS ALBERTO DE SOUSA - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC FABIO LUIS GONÇALVES HILSDORF - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC MARCIO LUIZ TEIXEIRA DE CAMARGO BARHUN - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos das testemunhas PC FABIO LUIS GONÇALVES HILSDORF e PC MARCIO LUIZ TEIXEIRA DE CAMARGO BARHUN.

Após, o réu LUCAS ALBERTO DE SOUSA foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em

vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MM^a. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo Dr. Promotor de Justiça foram apresentadas alegações finais, as quais foram gravadas através do sistema de mídia digital, disponibilizadas estas no Sistema SAJ.

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende, EM SEDE PRELIMINAR, que as provas obtidas nos autos, em especial as substâncias entorpecentes encontradas pelos Policiais, são ilícitas, eis que constituídas a partir da invasão indevida do domicílio. Isso porque, de acordo com os elementos colhidos durante o processo, percebe-se que não estavam presentes nenhuma das exceções para a mitigação da garantia fundamental prevista no art. 5º, XI, da Constituição da República. Como se observa dos depoimentos colhidos, tem-se que o ingresso dos agentes na residência em questão ocorreu sem autorização dos moradores (devidamente registrada por escrito e em gravação audiovisual, conforme determinou recentemente o C. STJ) e apenas em função de suspeitas de que o acusado estivesse guardando entorpecentes no local. Ainda que houvesse, em tese, suspeitas a respeito do imóvel, caberia aos agentes competentes diligenciarem na região, a fim de apurarem se a delatio criminis teria algum fundamento. Caso, nesta averiguação, constatassem, efetivamente, indícios de prática criminosa, deveriam, então, buscar autorização judicial para realização de campanhas (art. 53, II, da Lei nº 11.343/06), ou para a expedição do mandado de busca domiciliar para a colheita de elementos probatórios necessários à comprovação da infração, nos exatos termos do artigo 240 do Código de Processo Penal. Ademais, não se pode respaldar tal procedimento sob a assertiva de que o tráfico seria crime permanente. Com efeito, independentemente da natureza do delito (instantâneo ou permanente), a mitigação da garantia em voga não prescinde da constatação, ex ante, da situação flagrancial pelo agente que fará a incursão na residência, o que não ocorreu no caso. E, ainda que superadas tais considerações, entendendo-se que o flagrante posterior ao ingresso na residência convalide, em tese, a diligência policial e a própria prova colhida, cabe, então, observar que não é qualquer ato flagrancial que autoriza a invasão domiciliar, em respeito ao princípio constitucional da proporcionalidade. Isso porque a exceção aberta aos casos de flagrante delito evidentemente visa a permitir a invasão de residências em que um crime "natural" está sendo cometido; ouvem-se os gritos da vítima, os tiros do ladrão, as surras do pai na criança. Sempre hipóteses em que a vida humana, ou mesmo o patrimônio, correm perigo concreto e imediato, nada justificando que a hipótese de que haja entorpecentes escondidos, para futura comercialização, autorizem a invasão policial sem mandado judicial. Dessa forma, tendo sido a apreensão da maior parte dos entorpecentes diretamente ligada à invasão de domicílio, pois eles só foram (em tese) encontrados após a detenção do acusado e no interior do imóvel, de rigor reconhecer-se a nulidade do laudo de constatação e do laudo do exame químico-toxicológico, por constituírem provas ilícitas por derivação, nos exatos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal. Consequentemente, verifica-se que a denúncia oferecida pelo Ministério Público é ausente de justa causa por falta de comprovação da materialidade delitiva (art. 395, III, CPP), razão pela qual se requer seja declarada a nulidade do processo ab initio, em relação à imputação da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Entretanto, caso não seja acolhida a preliminar suscitada, quanto ao MÉRITO, a Defensoria Pública entende que as evidências levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao denunciado, razão pela qual deverá ocorrer a ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. Excelência, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório

robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Fabio, Policial Civil, declarou que receberam uma informação de que uma pessoa chamada Lucas estaria comercializando entorpecentes na vila em que ele residia. Foram passadas as características do autor do fato. ao chegarem no endereço indicado encontraram o réu, cujas características batiam com as da denúncia. Ele tentou se evadir, mas foi abordado. Inicialmente ele negou a denúncia, mas depois confessou informalmente o tráfico e indicou o local onde estava o entorpecente, no interior da sua residência. Ele permitiu a entrada na residência. Ele disse que vendia cada porção por R\$ 10,00 e ganhava três porções a cada 10 vendidas, pois estava com dificuldades financeiras. Não conhecia o acusado antes dos fatos. A testemunha Marcio, Policial Civil, declarou que receberam informação de que um indivíduo chamado Lucas estaria comercializando entorpecentes. Foram até o local indicado e avistaram o réu, que correu ao ver a viatura, mas foi abordado. Inicialmente, ele negou a denúncia, mas depois confessou informalmente e disse que as drogas estariam no interior de um saco de rações de cachorro. Sobre o entorpecente, o réu disse que vendia cada porção a 10 reais e ganhava 03 porções a cada 10 vendidas. Não conhecia o acusado antes dos fatos. O réu, em interrogatório, declarou que vendia entorpecentes, porém, as drogas que foram encontradas se destinavam ao seu consumo pessoal. É usuário de cocaína e maconha. Não conhecia os Policiais que efetuaram a sua prisão. Disse aos Policiais que, a cada 10 porções vendidas, ganhava 03 porções. Foram 10 cápsulas que foram encontradas. Portanto, o acusado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a prática do tráfico de drogas, declarando expressamente que as substâncias apreendidas em seu poder, na realidade, se destinavam ao seu consumo pessoal. Por outro lado, as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos Policiais responsáveis pela prisão do acusado, as quais, todavia, devem ser recebidas com reservas. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança pública do Estado ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem, em juízo, a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras dos agentes responsáveis pela prisão como fundamento exclusivo para uma condenação: "Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger." (TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11 - grifado). Ademais, no caso em pauta, observa-se que, a despeito da denúncia recebida (sequer comprovada documentalmente nos autos, diga-se de passagem), não foram visualizadas condutas que indicassem o envolvimento do réu no comércio de entorpecentes (p. ex., atendimento a possíveis compradores, entrega de objetos, recebimento de dinheiro, etc.) e não foram apresentados outros indivíduos como supostos usuários ou testemunhas presenciais das diligências. Por fim, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a

caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Dessa forma, ante a manifesta insuficiência probatória, a absolvição é medida de rigor, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Caso este E. Juízo entenda que apenas as substâncias encontradas em poder do réu lhe pertenciam, afastando-se a propriedade das demais substâncias, requer-se, então, a DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. Com efeito, ainda que se entenda que o acusado estava, de fato, com a posse das drogas, deve-se reconhecer que a capitulação do delito dada pelo Ministério Público, qual seja, a do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, mostra-se equivocada. Com a devida vênia, há de se reconhecer que não há nos autos indícios de que o acusado fosse comercializar as drogas apreendidas. Assim, no máximo, o réu poderia ser responsabilizado por portar drogas para fins de consumo pessoal, pois não foi demonstrado cabalmente o intuito lucrativo, não bastando a simples apreensão do entorpecente em poder do acusado para se justificar uma condenação

por tráfico. Inclusive, ainda que se queira dar total credibilidade à versão dos Policiais, vale observar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas nada diz quanto à sua destinação, eis que a quantidade necessária para a satisfação de um usuário é completamente variável. Para a configuração do crime de tráfico, não basta a simples apreensão da droga, sendo imprescindível a aferição de prova cabal da finalidade de mercancia dos entorpecentes por parte do réu, o que não foi o caso. Assim, pugna a defesa, caso não haja a absolvição, pela desclassificação do delito, com as consequências legais. Entretanto, acaso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer-se, então, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. É que, na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado, à época dos fatos, era tecnicamente primário. Ademais, não há prova de que o acusado participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido apenas em função da quantidade de entorpecentes que fora apreendida, que, aliás, nem mesmo se mostra elevada, na hipótese. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra “dedicação às atividades criminosas”, faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu, à vista da absoluta primariedade do denunciado. Além disto, o Decreto 5.015/04, que promulga a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, define, em seu artigo 2º, o conceito de organização criminosa: “Artigo 2º - Terminologia. Para efeitos da presente Convenção, entende-se por: a) “Grupo criminoso organizado” - grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material; (...). Do cotejo do texto legal acima citado, é evidente que não se configurou uma organização criminosa. Assim, quanto a “integrar organização criminosa”, é possível afirmar que a intenção do legislador foi vedar a aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo àquele que é membro de organização criminosa, ou seja, possui vínculo de forma ativa e permanente com a mesma, além de grande envolvimento com seus mecanismos e pessoas, o que, à evidência, não ocorre na hipótese em testilha. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: “No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o be

nefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida" (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 – grifado). Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, e que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, são absolutamente favoráveis ao acusado; (ii) a incidência, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea (ainda que extrajudicial) e da menoridade relativa; (iii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iv) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e às súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ, bem como diante da regra prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal; (v) a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em razão da Resolução do Senado nº 5 de 2012 e das inúmeras decisões do Supremo (Plenário e Turmas), reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.434/06, que continha tal vedação (v.g. STF – Segunda Turma – HC nº 110.920/MG – rel. Min. Carmen Lúcia – j. 19/02/2013); (vi) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que justifique a decretação de sua prisão preventiva".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

LUCAS ALBERTO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 11 de agosto de 2021, por volta das 11h30min, na Rua Kurt Nimuendaju, número 733, casa 6, bairro Paulista, nesta cidade e comarca de Piracicaba, guardava, para fins de tráfico, 10 (dez) gramas de cocaína, acondicionadas em 10 (dez) cápsulas plásticas, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais civis receberam denúncia anônima dando conta que um indivíduo de prenome LUCAS, morador da rua Kurt Nimoendaju, número 733, no bairro Paulista, estaria praticando tráfico de drogas. Os policiais foram até o local e depararam-se com o acusado no corredor da viela, próximo do endereço mencionado, sendo que, ao avistar a presença policial, o réu correu em direção a uma casa, mas foi alcançado e abordado pelos policiais. Indagado sobre a denúncia, inicialmente o acusado negou, mas acabou admitindo que possuía drogas em sua residência, informando que estariam escondidas no saco de ração do cachorro, onde os policiais encontraram e apreenderam a droga, efetuando a prisão do flagrante do acusado, que, tanto para os policiais, como no interrogatório, admitiu que as drogas se destinavam ao comércio ilícito, explicitando que vendia cada cápsula por R\$ 10,00, (recebendo três cápsulas a cada 10 vendidas), justificando a prática em razão de dificuldades financeiras.

O réu foi notificado nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 88) e apresentou defesa preliminar (fls. 91/96), seguindo-se a decisão que recebeu a denúncia e concedeu o benefício da liberdade provisória ao acusado (fls. 106/109).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e, após, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. O E. Supremo Tribunal Federal, a fim de coibir excessos e arbitrariedade,

assentou entendimento segundo o qual o ingresso em residência, sem autorização do morador e sem ordem judicial, para ser lícito, demanda quadro de fundada suspeita de situação de flagrante delito. Logo, os policiais somente podem adentrar em residência se tiverem dados concretos indicativos da ocorrência de um crime, impondo-se controle jurisdicional posterior da diligência para se definir se a ação policial era justificada ou não.

Confira-se, sobre o tema, o julgado em que assentado o entendimento do Pretório Excelso: "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso" (STF, RE nº 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes).

No caso em tela, os policiais esclareceram que receberam denúncia anônima dando conta de que pessoa com o prenome do réu e com suas características estaria traficando no local e, quando ali chegaram, o réu tentou empreender fuga ao avistá-los.

A abordagem do acusado e o consequente ingresso dos policiais no imóvel não constituiu ação arbitrária. Havia justa causa para a ação, sendo lícitas as provas daí decorrentes.

Ademais, os policiais atestaram que foram autorizados pelo réu a entrar na residência, bem como que ele colaborou com a ação, indicando onde estava a droga.

2. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10, pela fotografia de fls. 11 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 61/63, que trouxe resultado positivo para cocaína.

A autoria também é certa.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu confessou a prática do delito. Disse que residia em uma vila, na data dos fatos, estava fumando maconha quando os vizinhos informaram que havia policiais na rua. Narrou que se assustou e correu em direção a sua casa, porém, foi detido pelos policiais antes de ingressar

no imóvel. Afirmou que, ao ser abordado, foi-lhe perguntado se havia drogas em sua casa. Inicialmente, negou, mas depois acabou confessando que havia 10 (dez) "eppendorfs" de cocaína no interior do saco de ração do cachorro. Alegou que realizava a mercancia ilícita de entorpecentes porque estava passando por dificuldades financeiras, vendendo cada "eppendorf" pelo valor de R\$ 10,00 (fls. 04/05).

Em juízo, inovou. Disse que realmente falou para os policiais que estava traficando e por quanto vendia casa porção, mas a droga encontrada na sua casa era para seu uso. Aduziu que informou aos policiais que a cada dez porções de cocaína recebia o valor de três, mas as porções que foram encontradas na sua casa tinha comprado para seu uso.

A confissão prestada em sede policial, porém, foi corroborada pelos demais elementos de prova, não há como desprezá-la.

A propósito do tema os seguintes julgados:

Processo penal. Prova. Confissão extrajudicial. Posterior retratação judicial.

Eficácia probatória da confissão realizada perante a autoridade policial. A confissão vale, não pelo lugar onde é prestada, mas por seu próprio teor, sempre que confirmada pelo restante do conjunto probatório. (TJSP, 871392520098260050 SP 0087139-25.2009.8.26.0050, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 09/02/2012, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/02/2012).

"HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMARAM A CONVICÇÃO DO JULGADOR.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Não configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, corroborada por depoimentos colhidos na fase instrutória.2.

Embora não se admita a prolação do édito condenatório com base em elementos de convicção exclusivamente colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular e o Tribunal de origem apoiaram-se também em elementos de prova colhidos no âmbito do devido processo legal. (...)" (STJ, 115255 MS 2008/0199821-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/05/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2010).

"Não se pode perder de vista que, sem razão extraordinária, não é comum alguém mentir contra si próprio. E na espécie, não se vislumbram fatos que pudessem implicar no reconhecimento de uma falsa confissão na polícia. De mais a mais, insista-se, a confissão naquela fase merece eficácia probatória, porque crível e verossímil, fruto da clara correlação entre os testemunhos, tudo a permitir a responsabilização penal do recorrente. De mais a mais, a confissão policial pode prevalecer à retratação judicial, quando harmônica com o restante da prova, uma vez que aquela vale pelo grau de credibilidade que lhe seja inerente e não pelo local em que é colhida". (Revisão n.º 297.262/1, TACRIM, 4o Grupo de Câmaras, Relator: Luiz Ambra, RJTACRIM 35/497).

Com efeito, o policial civil Fábio Luís relatou que receberam informação de que pessoa de prenome Lucas, com endereço e características fornecidos, estaria comercializando entorpecentes na vila em que ele residia. Atestou que, ao chegar ao local, viram uma pessoa com as características fornecidas, que, ao notar viatura, correu, mas foi alcançado. Afirmou que, com ele, nada havia de irregular. Asseverou que ele foi questionado e, de início, negou a prática do crime, mas, depois, acabou dizendo que realmente estava vendendo entorpecentes e teria, na casa dele, dentro de um saco de ração, dez eppendorfs de cocaína. Informou que, com autorização do réu, entraram na casa e, no saco de ração, encontraram o entorpecente. Aduziu que o réu esclareceu que, a cada dez eppendorfs vendidos, três eram o lucro dele e ele estava no tráfico porque estava desempregado.

No mesmo sentido o depoimento do policial civil Márcio Luiz.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais civis não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial civil assume o compromisso de dizer a verdade do

que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de policiais civis é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes.

Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Enfim, o fato de os policiais civis terem recebido denúncia da traficância no local e, logo em seguida, terem visualizado o réu no lugar informado, o qual confessou, na fase extrajudicial, a traficância e indicou o esconderijo das drogas, que foram devidamente apreendidas, conduz à certeza quanto à autoria e a destinação do entorpecente ao comércio ilícito.

Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, cabendo anotar que, para sua configuração, não se exige qualquer ato de venda, bastando, como no caso em tela, que o agente guarde a substância entorpecente.

Consigno, outrossim, que o fato de o acusado ser usuário de entorpecentes, por si só, não infirma a acusação.

Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - RJTJSP, 101/498).

3. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, observo que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena-base em cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa, em seu valor mínimo legal.

Não há circunstâncias agravantes e, porque fixada a pena no mínimo legal, nenhuma atenuante pode reduzi-la.

Não há causas de aumento. De outro lado, não há notícia de que o réu integre organização criminosa ou se dedique a atividades ilícitas, razão pela qual reduzo a pena fixada de dois terços, nos termos do art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, totalizando um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Quanto à substituição da pena corporal por restritiva de direito, muito embora, em tese, possível, comungo do entendimento de que a benesse é incompatível ao condenado por crime de tráfico, não em função de impeditivo legal, mas pela periculosidade social presumida, incompatibilizando o autor de delito dessa natureza com atividades comunitárias ou assistenciais, na medida em que o recoloca em contato direto com grupo suscetível ao seu assédio (cf. Apelação nº 0004555-80.2014.8.26.0451, Rel. Des. Augusto de Siqueira, j. 26.01.17).

Observo que o art. 44 do Código Penal, em seu inciso III, expõe elementos a serem considerados quando da substituição da pena corporal por restritiva de direito, consignando, ao final, a necessidade de que a substituição seja "suficiente".

Na hipótese, a substituição é medida insuficiente para a prevenção do abjeto comércio que se difunde e fomenta a delinquência no país, sendo, portanto, de acordo com a regra prevista no inciso III do referido diploma penal, imperiosa a manutenção da pena privativa de liberdade.

No que tange à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, consigno que, com a edição do Novo Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal em razão do disposto pelo art. 3º do Código de Processo Penal, estabeleceu-se a necessidade de os juízes observarem o precedente ao julgar determinada matéria.

Com efeito, o art. 926 do Código de Processo Civil dispõe: "Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.". Já o art. 927 do mesmo código estatui: "Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.".

Prosseguindo, o art. 928 estabelece: "Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: I - incidente de resolução de demandas repetitivas; II - recursos especial e extraordinário repetitivos".

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n.118.533/MS, firmou entendimento no sentido de que o denominado tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda.

Nesse contexto, anotou a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no julgamento do Recurso Especial paradigma 1.329.088/RS, referente ao Tema 600 do Superior Tribunal de Justiça: "É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalícia, sob o rito dos recursos repetitivos".

E, de forma unânime, decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela interpretação da lei federal e sua correta aplicação, acompanhando o entendimento consolidado pela Corte Suprema, que o tráfico de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06) não é crime equiparado a hediondo, cancelando a súmula 512, editada em 2014 após o julgamento do REsp 1.329.088 sob o rito dos repetitivos.

Enfim, estando pacificada nas Cortes Superiores a não hediondez do tráfico privilegiado, sendo o réu primário e imposta pena inferior a quatro anos, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

4. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu LUCAS ALBERTO DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, fixado regime inicial aberto.

Oportunamente, expeça-se mandado de prisão a ser cumprido no regime aberto e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU e DEFENSOR foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MMª. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data.

2) Tendo em vista a fixação de regime aberto para cumprimento da pena, expeça-se termo de advertência em apartado concomitantemente com mandado de prisão de regime aberto. Cumprido o mandado, comunique-se o IIRGD e SARC.

3) Cumpra-se a Res. 09/85 do TJSP, oficiando-se ao IIRGD e TRE.

4) Expeça-se guia de recolhimento definitiva.

5) Sai o réu intimado na audiência realizada nesta data, 23/02/2022, para que efetue o pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias, no valor de R\$6.509,49,

equivalente a 203,61 UFESPs nos termos do Art. 50 do Código Penal e Art.479, caput, NSCGJ, sob pena de execução do débito a ser ajuizada pelo Ministério Público.
6) Oportunamente, archive-se.
Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo
JUÍZA DE DIREITO
[Assinado eletronicamente]